

1503158-45.2020.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... DE MEDEIROS pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico que lhes foram imputados na inicial acusatória.

8. A defesa dos acusados pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapopolis - SP - cep 14900-000

1503158-45.2020.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503158-45.2020.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jorge Luis de Medeiros e outro

Juiz de Direito: Dr. VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JORGE LUIS DE MEDEIROS e ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos (fls. 26/28 e 32/34), imputando-lhes as condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06.

Narra a inicial acusatória que, no dia 17 de dezembro de 2020, às 14 horas, no interior da residência situada na Rua Ismael Colete, n.º 250, Bairro Jardim Redenção, nesta cidade e comarca de Itápolis/SP, os denunciados, previamente associados com o adolescente KAINAN ARANTES BUENO, para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas, traziam consigo e mantinham em depósito 1,7 grama da droga Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, e diversas porções de cocaína, na forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando 51,55 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica (vide auto de exibição e apreensão de fls. 42/44, autos de constatação preliminar de substância entorpecente de fls.15/19 e laudos de exame químico toxicológicos de fls.123/134), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (fls. 141/143).

Devidamente notificados (fls. 194 e 186), os réus JORGE LUIS DE MEDEIROS e

ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA apresentaram resposta escrita, respectivamente, às fls. 191/196 e 203/207.

Denúncia recebida em 7 de julho de 2021, conforme decisão de fl. 231/237.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de agosto de 2021, ocasião em que foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Encerrada a instrução, foi deferido o pedido da defesa de expedição de ofício à Polícia Civil para encaminhamento de fotos e filmagens que ainda não tivessem sido juntadas aos autos (fls. 264/265).

Ofício n.º 03-IP221/20-AAG da Polícia Civil às fls. 291/304 e 338/349.

Alegações finais escritas apresentadas pelo representante do Ministério Público e pelo defensor, respectivamente, às fls. 308/317 e 330/337.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio

policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo auto de exibição, apreensão e constatação (fls. 15/19 e 42/44), pelo boletim de ocorrência (fls. 38/41), pelos documentos fotográficos (fls. 45/61), pelo auto de busca e apreensão (fls. 92/93), pelos laudos de exame químico toxicológicos (fls. 123/134), pelo relatório de investigação policial (fls. 136/138), pelo Ofício n.º 03-IP221/20-AAG da Polícia Civil (fls. 291/304 e 338/349) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria do crime de tráfico de entorpecentes é incontroversa em relação aos acusados ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA e JORGE LUIS DE MEDEIROS. Com efeito, restou demonstrado que no dia 17 de dezembro de 2020, às 14h00, no interior da residência situada na Rua Ismael Colete, n.º 250, bairro Jardim Redenção, nesta cidade e comarca de Itápolis/SP, os denunciados ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA e JORGE LUIS DE MEDEIROS, em concurso com o adolescente KAINAN ARANTES BUENO, traziam consigo e mantinham em depósito 1,7 grama de maconha e 51,55 gramas de cocaína, na forma de crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Conforme narrado na denúncia, o denunciado JORGE fazia uso do imóvel de sua propriedade, situado na Rua Ismael Colete, n.º 250, bairro Jardim Redenção, que tem localização estratégica, próxima a pontos de venda de drogas, sendo, ademais, de difícil acesso, porquanto possui apenas uma entrada, pela frente, que é protegida por muro alto e com portões que permaneciam sempre trancados. O outro morador da residência, o denunciado ADEMILSON, bem como outros dois adolescentes, desempenhavam a função de olheiros, ou seja, eram responsáveis por vigiar o imóvel e as cercanias e informar a respeito da chegada de policiais. Na residência em comento as drogas eram guardadas e mantidas em depósito para a venda clandestina. Ocorre que, no dia 09 de dezembro de 2020, o setor de investigações da Polícia Civil recebeu informações a respeito da prática do crime de tráfico de drogas no referido local, sendo deferida a expedição de mandado de busca e apreensão (processo n.º 1503128-10.2020.8.26.0274). Em cumprimento à ordem judicial, no dia dos fatos (17 de dezembro de 2020), policiais civis se dirigiram ao local, ocasião em que encontraram os denunciados na companhia de um maior e do adolescente KAINAN. Iniciadas as buscas, o policial civil EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO apreendeu uma porção de crack e pequenas porções de maconha em poder do acusado ADEMILSON. No interior da residência, em locais diversos, apreendeu-se a quantia de R\$ 950,00, em cédulas de pequeno valor. Ato contínuo, foi localizada uma porção de tamanho médio de crack no bolso de uma blusa de moletom, pendurada na porta do guarda-roupas, em uma meia, mais uma porção de tamanho médio, da mesma droga, a qual estava envolta em plástico preto.

Vejamos.

O acusado JORGE LUIS DE MEDEIROS, ao ser interrogado na fase policial, negou a autoria delitiva. Sustentou que na data dos fatos foi até a residência de seu tio ADEMILSON beber água e, quando lá estava, foi abordado por policiais civis. O interrogado estava no local há aproximadamente 20 minutos. Além do interrogado, estavam na residência de seu tio seu sobrinho BRUNO e o adolescente KAINAN. Nada foi localizado em poder do interrogado. Não viu se foi localizada droga na casa. Na residência de seu tio também reside o adolescente KAINAN. Às vezes vai até a residência de seu tio, sendo que neste mês essa foi a primeira vez que esteve no local. O interrogado não comercializa entorpecentes (fl. 11).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado JORGE LUIS DE MEDEIROS negou a autoria delitiva. Narrou que no dia dos fatos foi até a casa de seu tio ADEMILSON, por volta das 13h30. Chegando lá, percebeu que ADEMILSON, que era dependente químico, estava um pouco abalado. Aproximadamente dez minutos depois policiais

entraram no imóvel e revistaram a casa. Os agentes públicos apreenderam drogas que estavam com seu tio. Em seguida eles foram até o quarto, chamaram por ADEMILSON, e disseram que havia mais drogas no referido cômodo. O menor KAUAN estava no interior da casa e o adolescente KAINAN estava do lado de fora. Não havia nenhum sofá do lado de fora da casa. Seu tio ADEMILSON já foi internado para tratamento de seu vício em entorpecentes.

O acusado ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA, ao ser interrogado na fase policial, negou a autoria delitiva. Sustentou que na data dos fatos estava em sua residência, quando policiais civis lá estiveram. Os policiais iniciaram as buscas em sua residência e no quarto, onde pernoita um rapaz de apelido OREIA, não sabendo o interrogado dizer seu prenome, foi localizado certa quantidade de droga. Os policiais também localizaram droga (maconha e crack) no bolso do interrogado, droga esta que se destinaria a seu próprio consumo. JORGE, BRUNO e KAINAN também estavam na residência do interrogado para beberem água. O interrogado não comercializa entorpecentes e não guarda drogas para JORGE em sua residência. Não é olheiro do tráfico (fl. 13).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA negou a autoria delitiva. Sustentou que a casa em que ocorreram as diligências pertence ao interrogado. A droga apreendida pelos policiais era para o consumo do interrogado. Por seu turno, os entorpecentes localizados pelos agentes públicos no quarto pertencem a "OREIA", um menor de idade cujo nome o interrogado desconhece. Além do interrogado, estavam na casa JORGE e o menor KAINAN. Conhecia KAINAN há 10 dias e esclarece que ele estava no local para beber água. OREIA não estava na casa. Não havia sofá do lado de fora do imóvel. O interrogado é dependente de crack e de maconha, já tendo sido internado por duas vezes.

As testemunhas EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO e JOSÉ PIRES GARCIA FILHO, policiais civis, em solo policial, disseram que atuam no setor de investigações e há tempos estão investigando o acusado JORGE, pois é do conhecimento da Polícia Civil que ele está envolvido com o tráfico de drogas. Durante as investigações, verificaram que JORGE se utiliza de algumas pessoas para a prática do delito. Há alguns meses, JORGE passou a residir com ADEMILSON e ambos passaram a traficar. Tanto JORGE como ADEMILSON vendiam drogas no imóvel, sendo que ADEMILSON também exercia a função de olheiro. Nas várias vezes em que os depoentes e seus colegas diligenciaram naquele bairro, puderam observar que, além de ADEMILSON, os adolescentes KAUAN FRANCISCO CORDEIRO, vulgo 'Oreia', e KAINAN ARANTES BUENO também eram incumbidos de vigiar o local. Observaram, ainda, que a casa onde JORGE e ADEMILSON residem era protegida por um muro alto e permanecia com os portões trancados. Tais fatos foram relatados na informação 327/20, que culminou com a representação para busca domiciliar. Na data de hoje, de posse da ordem judicial, juntamente com outros policiais civis, foram até a casa de JORGE e ADEMILSON. Como já se esperava, os portões estavam trancados por dentro, sendo necessário o uso de escadas para escalar o muro. Naquela casa, estavam JORGE, ADEMILSON, KAINAN e BRUNO HENRIQUE DA FONSECA. A todos foi dado ciência do teor das diligências, mas eles negaram que havia drogas na casa. Em revista pessoal, foi encontrada uma porção de crack e pedaços de maconha no bolso da bermuda de ADEMILSON. Com os outros indivíduos, nada de ilegal foi encontrado. Iniciando as buscas, em um dos cômodos, foi apreendida a importância de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), em cédulas de pequenos valores (dois, cinco dez e vinte reais), sendo que o dinheiro estava guardado em vários locais. Continuando as buscas, localizaram uma porção de tamanho médio, de crack, envolta em plástico filme, sendo que a droga estava em pedaços. Logo após, localizaram outra porção, envolta em plástico de cor preta, com vários pedaços de crack. Na casa também apreenderam dois telefones celulares. Das pessoas abordadas na casa, as investigações até o momento não apontaram o envolvimento de BRUNO com o tráfico de drogas, mas somente o de JORGE, ADEMILSON e do adolescente KAINAN. Diante dos fatos, deram voz de prisão a JORGE e a ADEMILSON e, juntamente com as drogas, apresentaram-nos nesta Unidade. (fls. 03).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO e JOSÉ PIRES GARCIA FILHO narraram que receberam denúncias de que o acusado JORGE e os adolescentes kauan e kainan, além de outra pessoa

posteriormente identificada como sendo o acusado ademilson, estariam vendendo drogas na Rua Ismael Coleti, n.º 250. Realizaram diligências no local, porém não havia como fazer campana sem serem notados, pois havia olheiros em frente à residência. Tiraram fotos e requereram um mandado de busca para confirmarem a suspeita de tráfico no local. De posse do mandado de busca e apreensão, no dia 17 de dezembro de 2020 foram até o referido imóvel. Tiveram que pular o muro, usando uma escada, pois os acusados travavam o portão por dentro para dificultarem o acesso ao local. No interior da casa estavam Jorge, adEmilson, kauan e kainan. Foi feita revista pessoal, ocasião em que foi apreendida, com adEmilson, uma porção de crack e porções de maconha. Nada de ilícito foi encontrado em poder de JORGE. Indagados, eles disseram que não havia mais drogas na casa. Porém, o policial José Pires revistou os cômodos da casa e encontrou crack em uma blusa de moletom e em uma meia, bem como R\$ 950,00 em espécie. De acordo com as denúncias recebidas, JORGE era morador da casa e havia se juntado a outra pessoa. Não conheciam adEmilson, embora ele tivesse sido fotografado. Sabiam que os adolescentes kauan e kainan trabalhavam para Jorge. ademilson já havia sido visto em diligências anteriores trabalhando como olheiro. ademilson ficava no sofá como olheiro, ao lado de kauan e kainan. As fotografias foram anexadas com a informação prestada ao Delegado de Polícia. Não sabe se as filmagens estão nos autos. Já conhecia JORGE, mas não ADEMILSON. Não sabe se ademilson é viciado ou já foi internado. No momento da prisão, ADEMILSON disse que a droga que estava em seu poder era para uso. Não se recorda do que Jorge disse.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

Lado outro, é bastante comum que traficantes se utilizem de crianças ou adolescentes para o exercício da atividade, seja para isentar de responsabilidade o autor do fato imputável, seja porque a sanção imposta ao menor infrator é substancialmente mais branda. No caso dos autos, os elementos de prova acima destacados atestam de forma inequívoca que os acusados ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA e JORGE LUIS DE MEDEIROS praticou o delito de tráfico de entorpecentes em concurso com o menor KAINAN ARANTES BUENO.

5. A autoria do crime de associação para o tráfico é incontroversa em relação aos acusados ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA e JORGE LUIS DE MEDEIROS.

5.1. O delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 resta caracterizado quando duas ou mais pessoas se associarem (reunirem-se, juntarem-se) com a finalidade de praticarem (realizarem, cometerem) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006.

Como bem esclarece Guilherme de Souza Nucci, cuida-se da “associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes”. De acordo com o referido autor, “a associação criminosa há de ser estável e permanente. Do contrário, seria somente um concurso de pessoas” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 411 – grifo meu).

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a

paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, conclui-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para prática do crime pretendido. [...]” (HC 124.164, 2ª T., rel. Teori Zavascki, j. 11.11.2014 – grifo meu).

Esse é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. II – De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006” (REsp 1.113.728/SC, 5ª T. rel. Felix Fischer, 29.09.2009 – grifo meu).

Como esclarece Guilherme de Souza Nucci, “a advertência feita no tipo penal (reiteradamente ou não) quer apenas significar que não há necessidade de haver habitualidade, ou seja, não se demanda o cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos arts. 33 e 34, bastando a associação com o fim de cometê-los” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 414 – grifo meu).

5.2. No caso dos autos, restou demonstrado que os réus ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA e JORGE LUIS DE MEDEIROS e o adolescente KAINAN ARANTES BUENO, se associaram para o fim de praticarem reiteradamente as condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, entre elas a de trazer consigo e manter em depósito drogas para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Com efeito, extrai-se da prova dos autos que os denunciados ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA e JORGE LUIS DE MEDEIROS e o adolescente KAINAN ARANTES BUENO, estavam há tempos conjugando esforços com o propósito de distribuírem substâncias entorpecentes no município de Itápolis.

De acordo com o relatório de Informação n.º 327/2020, datado de 09/12/2020, subscrito pelos investigadores EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO e DOUGLAS CARDILLI, o Setor de Investigações da Polícia Civil, bem como a Polícia Militar, receberam diversas denúncias da prática de tráfico de entorpecentes situada na Rua Ismael Colete, n.º 250, bairro Jardim Esperança II, nesta cidade e comarca de Itápolis/SP. Restou apurado que parte da droga ficava armazenada no interior do imóvel e a outra parte era embalada e distribuída a vários adolescentes, entre os quais foram identificados KAINAN ARANTES BUENO e KAUAN FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA, vulgo “OREIA” (fl. 339).

A Polícia Civil tirou fotografias do local e dos pontos de vigia utilizados pelos olheiros nas proximidades da residência, sendo as referidas fotografias datadas do dia 10/12/2020 (fls. 343/345).

Consta ainda dos autos denúncias de tráfico de entorpecentes recebidas pela Polícia Militar nos dias 27/10/2020 e 02/12/2020 (fl. 349).

Em seus depoimentos, os policiais civis EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO e JOSÉ PIRES GARCIA FILHO esclareceram que o acusado JORGE LUIS DE MEDEIROS vem sendo investigado há tempos por seu envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes, restando apurado que ele teria passado a residir com o corréu ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA, seu tio, no imóvel da Rua Ismael Colete, n.º 250, Jardim Esperança II, para juntos traficarem drogas. Os policiais apuraram, ainda, que ADEMILSON e os adolescentes KAUAN e KAINAN exerciam a função de “olheiros”, utilizando um sofá que ficava nas proximidades do imóvel (conforme atestam as fotografias de fls. 343/345, tiradas no dia 10/12/2020, ou seja, dias antes da prisão em flagrante dos acusados (17/12/2020)).

Em suma, restou evidenciado a prévia reunião de interesses e propósitos entre os acusados e o menor para a prática dos delitos descritos na inicial, ficando patente a conjugação de esforços e a associação de todos os envolvidos com o único propósito

de distribuição da droga.

6. A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da inimputabilidade dos acusados e sua absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial.

Não há como ser acolhido tal pleito.

In casu, não há qualquer indício de que os réus, ao tempo dos fatos, fossem inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de se comportarem segundo tal entendimento, não sendo suficiente a alegação de que, na data dos fatos, teriam feito uso de substâncias entorpecentes ou de álcool.

Nos termos do caput, do artigo 45, da Lei n.º 11.343/2006, "É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" (grifo meu).

Referido dispositivo legal deve ser interpretado conjuntamente com os artigos 26, 27 e 28 do Código Penal, que igualmente tratam da inimputabilidade como causa de exclusão da culpabilidade. Como bem destaca Guilherme Nucci, "o art. 45 é desnecessário, diante dos arts. 26, 27 e 28 do Código Penal. Quem é viciado em qualquer substância entorpecente (incluindo-se, nesse contexto, o álcool), para o atual conceito médico, é doente mental. Portanto, o disposto no art. 26 seria suficiente tanto para quem padece de uma enfermidade mental, como, por exemplo, a esquizofrenia, como também para aqueles que são dependentes de drogas em geral" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 451 - grifo meu).

Pois bem. A teor do § 1º, do artigo 28, do Código Penal, apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é capaz de excluir a imputabilidade, desde que, em razão da ingestão de álcool ou de substância de efeitos análogos (e, acrescentamos, do uso de drogas e outras substâncias entorpecentes), o agente seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O caso dos autos, no entanto, amoldar-se-ia, em tese, à hipótese contemplada no inciso II, do caput, do artigo 28, do Estatuto Repressivo, segundo o qual a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool, drogas ou outra substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria: TJMG - Apelação Criminal n.º 1.0672.14.020730-5/001, 7ª Câmara, Relator(a): Agostinho Gomes de Azevedo, 11/06/2015; TJRS - Apelação Criminal n.º 700581169478, 2ª Câmara, Relator(a): José Ricardo Coutinho Silva, 21/05/2015.

Além disso, não requereu a defesa, no momento processual oportuno, a instauração do incidente de insanidade previsto no artigo 149 do CPP, estando precluso seu direito de produzir prova pericial para comprovar tal alegação.

Por fim, e não menos importante, "a implementação do incidente não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado" (STJ - HC 375.266/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017), o que, a meu sentir, não é o caso dos autos, conforme acima demonstrado.

7. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(s) acusado(s) ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA e JORGE LUIS DE MEDEIROS pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico que lhes foram imputados na inicial acusatória.

8. A defesa dos acusados pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às

circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas").

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, “para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública” (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 - grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giraldeili, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

In casu, a quantidade de entorpecentes apreendida (1,7 grama de maconha e 51,55 gramas de cocaína, na forma de crack) e sua forma de acondicionamento (em diversas porções, que facilitam o transporte e comercialização) revelam a intenção dos denunciados de praticarem a traficância ilícita.

Com efeito, conforme se extrai de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: a) um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5g a 1,0g do entorpecente; b) uma “fileira” de cocaína é confeccionada com 0,1g a 0,125g da droga, aproximadamente; c) uma pedra de crack tem, em média, 0,2g a 0,25g.

Confira-se: Apelação Criminal 1500949-81.2019.8.26.0228; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019; Apelação Criminal 0000617-39.2016.8.26.0247; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018; Apelação Criminal 0000244-11.2015.8.26.0613; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016.

Com base nesses dados, conclui-se que a quantidade de droga apreendida (1,7 grama de maconha e 51,55 gramas de cocaína, na forma de crack) seria suficiente para produzir diversas porções individualizadas, ou seja, era destinada a entrega a consumo de terceiros.

Cabe ainda ressaltar que, embora os réus não tenham sido flagrados comercializando drogas, há nos autos elementos indicativos de que eles estavam praticando o tráfico de drogas, entre os quais: a) a existência de diversas denúncias anônimas relatando o imóvel dos acusados era utilizado pela prática do tráfico de entorpecentes, tendo sido encontradas drogas no referido local por ocasião a prisão em flagrante dos denunciados; b) policiais realizaram campanhas e verificaram que um dos acusados e dois menores atuavam como “olheiros”; c) o acusado JORGE é conhecido nos meios policiais como traficante de drogas, já tendo sido processado e condenado pela prática do referido delito.

8. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

No caso em exame, restou demonstrada a prática, pelos acusados do delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo, pois, incabível a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça “Configurado o crime de associação para o tráfico, fica vedada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por expressa determinação legal” (HC 349.8378/SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, DJ 03/05/2016 – grifo meu).

Além disso, embora primário e possuidor de bons antecedentes, o acusado JORGE LUIS DE MEDEIROS se dedica à prática de atividades criminosas, porquanto ostenta outra condenação criminal não definitiva relativa a prática de tráfico de drogas praticado antes daquele que é objeto da presente ação penal: processo nº 1501345-17.2019.8.26.0274. Conforme já decidiu a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06” (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017 – grifo meu).

Finalmente, de acordo com os policiais militares, os acusados já eram conhecidos nos meios policiais por envolvimento com tráfico de entorpecentes, tendo a prisão em flagrante dos réus sido precedida do recebimento, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, de diversas denúncias anônimas apontando o local dos fatos como ponto de venda de entorpecentes.

II.3 – Da dosimetria das penas

II.3.1 – Acusado JORGE LUIS DE MEDEIROS

II.3.1.1 – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente. Isto posto, estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. “Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 – grifo meu).

Reconheço a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.346/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6. Fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II.3.1.2 – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

1. Circunstâncias judiciais

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente.

Isto posto, estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Reconheço a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.346/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6. Fixo a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II.3.1.3 – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando que o agente, mediante mais de uma ação, praticou 2 delitos, reconheço o concurso material entre o crime de tráfico de drogas (5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa) e o crime de associação para o tráfico (3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa), razão pela qual, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas, fixando-as em 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa.

II.3.1.4 – Outras disposições

1. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, “a”, e 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal, considerando-se: a) a quantidade de pena aplicada; b) que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente; e c) que o réu não é reincidente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

2. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

3. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268, SP).

II.3.2 – Acusado ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA

II.3.2.1 – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1. Circunstâncias judiciais

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente. Isto posto, estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Deixo de reconhecer a atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, por se tratar de confissão qualificada. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013. Esse é também o entendimento do TJSP: Apelação Criminal 9000001-11.2014.8.26.0301; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019.

Isto posto, estabeleço a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Reconheço a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.346/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6. Fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II.3.2.2 - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

1. Circunstâncias judiciais

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente.

Isto posto, estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Reconheço a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.346/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6. Fixo a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II.3.2.3 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando que o agente, mediante mais de uma ação, praticou 2 delitos, reconheço o concurso material entre o crime de tráfico de drogas (5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa) e o crime de associação para o tráfico (3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa), razão pela qual, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas, fixando-as em 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa.

II.3.2.4 - Outras disposições

1. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, “a”, e 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal, considerando-se: a) a quantidade de pena aplicada; b) que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente; e c) que o réu não é reincidente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

2. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

3. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268,SP).

III – DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

a) condenar o acusado JORGE LUIS DE MEDEIROS como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

b) condenar o acusado ADEMILSON MEDEIROS DE SOUZA como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva dos acusados e nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva (decretada em 18/12/2020 e mantida em 17/03/2021, 11/06/2021, 10/09/2021 e 03/12/2021), que continua necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: “HABEAS CORPUS – Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator

(a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá

- 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Incluam-se o nome dos condenados no rol dos culpados.

Notifiquem-se os condenados para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de